

1524464-14.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO DE LIMA LUIZ

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290023/2020 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 14799116 - 02º D.P. BOM RETIRO, 4233/20/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2290023 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1524464-14.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524464-14.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290023/2020 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 14799116 - 02º D.P. BOM RETIRO, 4233/20/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2290023 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALEXSANDRO CORDEIRO DE JESUS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO DE LIMA LUIZ

Vistos.

1 O relatório

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Alexsandro Cordeiro de Jesus e V. S. C., imputando-lhes a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c com art. 61, inciso II, alínea "j", do CP.

Narrou a peça acusatória (fls. 1-4) que:

Consta ainda que na Rua Alameda Dino Bueno, 121, Santa Cecilia, neste município e comarca da capital, por volta de 11:00hs, ALEXSANDRO CORDEIRO DE JESUS (já qualificado) e V. S. C. (qualificado a fl. 13), agindo com unidade de propósitos e desígnios, guardavam para fins de venda e comércio ilegal, 18 invólucros contendo cocaína; 46 invólucros de Maconha; 1 tijolo composto por Maconha e 27 invólucros de Crack e um galão plástico com cerca de 2000 mililitros de Cloreto de Metileno; além de duas balanças de precisão e um rolo de fita adesiva, em desacordo com

autorização legal ou regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fl. 10/11; laudo de constatação de fl. 30/34; massa líquida total do CLORETO DE METILENO/DICLOROMETANO: 2000 ml; massa líquida total da TETRAHIDROCANNABINOL: 349,9g; massa líquida total de COCAÍNA 70g).

ALEXSANDRO ainda trazia consigo para fins de venda e comércio ilegal, 27 papé debates de cocaína, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

Segundo o noticiado, ALEXSANDRO, caminhava pela via pública e ao avistar policiais militares em patrulhamento, esboçou atitude suspeita, assim, os policiais realizaram a abordagem.

Em revista pessoal, o policial encontrou em poder do acusado, 27 papé debates de cocaína.

No decorrer dessa abordagem, os policiais indagaram sobre a localização da residência do acusado. ALEXSANDRO informou que ficava na mesma rua, notadamente, em frente ao local em que a abordagem ocorreu.

No local, a entrada dos policiais foi franqueada pelo indiciado. No interior da residência, dentro de um quarto, V. foi encontrada com uma mochila marrom que continha 18 invólucros contendo cocaína; 46 invólucros de Maconha; 1 tijolo composto por Maconha; 27 invólucros de Crack. Além de, duas balanças de precisão e um rolo de fita adesiva. Também, foi encontrado no quarto um galão plástico com cerca de 2000 mililitros de Cloreto de Metileno.

ALEXSANDRO foi preso, conduzido à Delegacia de Polícia e, formalmente interrogado, permaneceu em silêncio (fls. 05). V. foi presa, conduzida à Delegacia de Polícia e, formalmente interrogada, negou os fatos. (fls. 06).

A elevada quantidade de droga apreendida e a forma como estava embalada demonstram que as substâncias se destinavam ao comércio ilícito.

Em decisão de fls. 114 foi determinada a citação e notificação do acusado e determinada a soltura de V. S. C., adolescente.

Às fls. 128-129 foi apresentado aditamento à denúncia.

Recebido aditamento à denúncia (fl. 148), determinando a exclusão da adolescente do polo passivo e remessa de cópia dos autos à vara competente para apuração de ato infracional

O acusado apresentou defesa preliminar às fls. 161-162.

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi recebida a denúncia e requisitada data para audiência de instrução e julgamento (fl. 163).

Agendada audiência para dia 27 de outubro de 2022 (fls. 171-174).

Realizado o ato, foi (foram): [a] colhidas provas testemunhais (audiência virtual); e [b] interrogado o réu.

Na fase do artigo 402, do CPP, as partes nada requereram.

Após concessão de prazo, foram apresentadas alegações finais (fls. 193-205 e 209-233).

2 A fundamentação

2.1 A preliminar

2.1.1 A autorização para ingresso na residência

A entrada forçada em domicílio tem natureza excepcional e, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição da República de 1988 (CR/88), só se justifica em casos de: [a] prestação de socorro; [b] desastre; [c] flagrante delito; e [d] determinação judicial (neste último caso, durante o dia - CPP, art. 241).

A partir de uma interpretação teleológica do referido dispositivo constitucional, é possível constatar então que a quebra da inviolabilidade domiciliar só se dá, em regra, mediante determinação judicial prévia e durante o dia: trata-se de medida restritiva de direito fundamental submetida a reserva jurisdicional.

Excepcionalmente, nas três situações de urgência elencadas no referido dispositivo normativo (prestação de socorro, desastre e flagrante delito), é possível a entrada forçada em domicílio independentemente de autorização judicial prévia, e em qualquer hora do dia.

No julgamento do RE 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou a orientação de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em

fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". Assim, caso o agente policial verifique fundadas razões da ocorrência de flagrante delito em determinada residência, autoriza-se a imediata entrada forçada em domicílio, a qualquer tempo, independentemente da prévia expedição de mandado judicial de busca, pois em tal situação há presunção de urgência para a repressão imediata da conduta criminosa atualmente em curso, o que justifica a postergação do controle jurisdicional da validade do ato, na linha das situações urgentes já previstas no art. 5º, XI, da CR/88.

Nessa ordem de ideias, vale notar que, desde o julgamento do RE 603.616/RO pelo Plenário do STF, evidenciou-se na jurisprudência que o standard probatório exigido para a expedição de mandado judicial de busca domiciliar (CPP, art. 240) e o standard probatório exigido para a entrada policial forçada em domicílio diante de flagrante de crime permanente (CR/88, art. 5º, XI) é exatamente o mesmo: fundadas razões da ocorrência da infração penal e da existência de elementos de convicção quanto a ele no interior da residência.

Assim, tanto a validade da entrada policial forçada em domicílio diante de flagrante de crime permanente quanto a validade do mandado judicial de busca domiciliar são analisadas à luz do mesmo critério: com base em seus fundamentos (fatos de conhecimento anterior à medida), e não com base em seus resultados (fatos de conhecimento posterior à medida).

Logo, se o policial promove a entrada policial forçada em domicílio a partir de fundadas razões quanto à situação de flagrância de crime permanente, a medida não será invalidada apenas em razão de ter tido resultado negativo (não obtenção de prova do crime). O mesmo raciocínio se aplica ao mandado judicial: a decisão que determina sua expedição será válida se estiver devidamente fundamentada em fundadas razões do ilícito, e não se o resultado do cumprimento do mandado for positivo.

No caso em tela, conforme narrado em audiência, houve situação de suspeita diante do comportamento do acusado. Ademais, este franqueou o ingresso no local onde estava hospedado, sendo encontradas as drogas em local escondido. A despeito dos precedentes mencionados pela defesa, inviável sua aplicação, eis que a situação se deu em 2020, quando ainda não existente o entendimento acerca da necessidade de registro da autorização, e sua aplicação retroativa implicaria em insegurança jurídica.

Destarte, rejeito a preliminar aventada.

2.2 O mérito

2.2.1 O crime de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06)

Na peça exordial, o Ministério Público do Estado de São Paulo imputa a prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 ao réu

A materialidade e a autoria são comprovadas pelos seguintes elementos: [a] boletim de ocorrência (fls. 11-13); [b] auto de exibição e apreensão (fls. 14-15); [c] laudo de constatação (fls. 34-38); [d] laudos periciais definitivos (fls. 134-137, 138-140, 141-143 e 144-146); e [e] depoimentos colhidos em audiência de instrução. Com efeito, tanto laudo de constatação quanto os definitivos fizeram a indicação de que, nos objetos analisados, foi observada a presença de invólucro plástico contendo 2000 (dois mil) ml da substância cloreto de metileno/diclorometano, popularmente conhecida como lança-perfume, invólucro plástico contendo 78,2g (setenta e oito inteiros e dois décimos) da substância tetrahidrocannabinol, invólucro plástico contendo 54,1g (cinquenta e quatro inteiros e um décimo) da substância cocaína, invólucro plástico contendo 271,7g (duzentos e setenta e um inteiros e sete décimos) da substância tetrahidrocannabinol, invólucro plástico contendo 15,9g (quinze inteiros e nove décimos) da substância cocaína.

Referidas substâncias são consideradas como droga, nos termos do previsto no parágrafo único do art. 1º da Lei n. 11.343/2006, o qual estabelece considerar-se como tal "as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União". A lista mencionada foi indicada nos laudos periciais logo após a identificação de cada uma das porções.

No que tange à caracterização do tráfico, vê-se que pela forma em que acondicionadas as substâncias (vários invólucros, conforme fotografia de fl. 38), estavam separadas e preparadas para posterior venda. Ademais, a variedade de drogas, a quantidade, bem como a presença de duas balanças de precisão e de rolo de papel tipo filme, sem que houvesse explicação para sua posse, corroboram para a caracterização do tráfico.

De outro turno, os depoimentos fazem concluir no mesmo sentido.

A testemunha Policial Militar José Américo dos Santos afirmou que houve confronto entre usuários de entorpecentes da crackolândia com guardas civis; estava fazendo patrulhamento pela área; avistaram o réu saindo de uma pensão; ele saiu, quando olhou e viu a viatura, voltou para a pensão, o que chamou a atenção; fizeram a abordagem e durante a abordagem foram localizados entorpecentes com ele; falou que era morador dessa pensão; perguntaram se tinha algo mais, ele falou que não, que poderiam olhar; ele concedeu acesso e no interior da pensão escondeu entorpecente atrás da cama dele; esse entorpecente era ainda para ser embalado; havia maconha, lança perfume, essas coisas; na abordagem na via, salvo engano, havia maconha e cocaína; havia quantidade para distribuir ali na região para os demais usuários, porém o restante estava no quarto dele para ser embalado; se recorda da existência de uma menor de idade junto com ele; o réu tentou falar que a droga era dela; ficou um jogando pro outro; ele falou que estava só passando uma noite com ela e a droga era dela; ela falou que a droga era dele; se recorda da apreensão também de petrechos para o tráfico de drogas; as drogas estavam próximo da cama dele, escondidas; a pensão tem vários usuários de drogas, então ele escondeu por medo; quando ele falou que não tinha mais nada, o fez porque sabia que a droga estava escondida; os dois de imediato não queriam assumir, jogando um para o outro; não conhecia ele antes da abordagem, pois ali é muito rotativo; sobre as drogas que estavam com ele, ele disse que era para uso próprio; ele foi abordado assim que saiu da pensão; como não olhou para o lado que a viatura estava vindo, foi para o lado oposto, quando olhou para trás, tentou voltar mais rápido, foi o que chamou a atenção; o quarto não se recorda o andar ou número; entraram em contato com funcionário apenas para identificar qual era o quarto dele, que estava no apelido dele, que é "alemão"; fizeram documento no boletim sobre ser franqueada a entrada; à essa época ainda não havia câmeras; a V. foi abordada dentro da casa; não visualizaram ele saindo ou entrando no quarto, porque nem poderiam; estava ao lado da cama escondidas atrás do móvel do lado da cama; e ele aparentava ser usuário, porém não estava como os demais, estava com vestimenta limpa, com local para viver. Em interrogatório, o acusado Alexsandro Cordeiro de Jesus disse que a acusação não é verdadeira; no dia dos fatos se encontrava em estado de rua na crackolândia; nesse momento estava tendo confronto entre os GCMS e os usuários; após alguns minutos, a multidão se esparramou; uma viatura da força tática abordou e perguntou se tinha passagem; possuía um monte de cachimbo, corote, tudo que usava; nesse momento disse que tinha passagem; falou que estava de regime aberto há 9 meses; perguntaram a matrícula; escutou falar que nada constava; disseram que teria que ir para a delegacia e que lá iria saber o porquê; passados alguns minutos, chegou outra viatura; visualizou uma moça lá dentro da viatura; foram para a delegacia; perguntava por que estava lá, e respondiam que quando fosse a hora iria saber; após algumas horas levaram para fazer corpo delito; retornaram no 2º DP, pegaram a moça, colocaram na viatura junto e chegando em outra DP mandou o interrogado descer; questionou as razões e falaram que iria saber; na segunda feira foi transferido para o CDP de Mauá; somente foi ter ciência das acusações dois meses depois; de lá para cá, foi tudo que aconteceu; não sabe quem é essa mulher; estava na vida porque se aprofundou no crack; está há 2 anos preso, abandonado; está colhendo o que plantou; sozinho não consegue ajuda, é doente; tem passagens, mas não praticou os fatos narrados na denúncia; conhece a pensão; e não vivia na pensão, estava vivendo na rua.

Logo, do que se viu, as drogas estavam preparadas para venda, apreendidas com o réu no local dos fatos, no momento da abordagem policial. Ao assim agir, incidiu no disposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o qual classifica como crime "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor

à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, devendo incidir nas penas a ele cominadas.

Acerca das teses de defesa, saliento que o procedimento observou as determinações legais incidentes, não havendo se falar em falta de materialidade pela falta de observância da cadeia de custódia. Ademais, em se tratando de objeto (as drogas), inviável a simples manutenção do local para que algum perito até lá se desloque e faça a apreciação do material (notadamente porque necessária a utilização de materiais de laboratório).

Além disso, não há qualquer dúvida sobre a imputabilidade do réu em relação a tais fatos, o que sequer chegou a ser ventilado na hipótese.

2.3 A dosimetria da pena

No que tange à dosimetria da pena, destaco, na primeira fase (pena-base), que, de acordo com o art. 59 do CP: [a] a culpabilidade (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie; [b] inexistem informações suficientes acerca da conduta social (meio como se comporta no seio da sociedade) ou da personalidade (características pessoais advindas de sua psique); e [c] os motivos (as razões de sua prática), as circunstâncias (modo em que ocorreu) e as consequências (situações advindas da prática) também não se apresentam destoantes do que normalmente se espera nesses casos.

Há, no entanto, dois maus antecedentes que devem ser considerados (autos n. 76850-25/2011, fl. 51, pena extinta em 30-6-2015, fl. 47; e autos n. 76850-67/2008, fl. 52, pena extinta em 09-2-2011, fl. 46). A natureza e a quantidade das drogas devem ser consideradas nesta fase e justificam o aumento da pena base do réu, uma vez que se trata de elevada quantidade de entorpecentes os que foram encontrados em sua residência, notadamente pela diversidade.

Saliento, por oportuno, que: [a] “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula n. 444 do STJ); e [b] “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula n. 241 do STJ).

Dessa forma, majoro a pena em 1/4 (um quarto) e fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase (pena-provisória), destaco a existência da agravante de reincidência (autos n. 1510-87/2017, fl. 51) e a inexistência de atenuantes.

Não reconheço a agravante de crime praticado em caso de calamidade pública (em razão da pandemia de COVID-19), nos termos do art. 61, inciso II, 'j', do CP, porquanto referido estado não teve relação direta com a prática do crime (no mesmo sentido, desta Corte: TJSP; Apelação Criminal 1520980-88.2020.8.26.0228; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/04/2021; Data de Registro: 06/04/2021).

Saliento que: [a] “a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula n. 231 do STJ), o que, por consequência, também inviabiliza sua majoração além do máximo; [b] nos termos do já destacado acima, “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula n. 241 do STJ); e [c] “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal” (Súmula n. 545 do STJ).

Diante disso, majoro a pena em 1/6 (um sexto) e estabeleço a pena-provisória, nessa segunda fase, em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo como pena-definitiva o mesmo patamar acima previsto para a pena-provisória. Saliento não ser cabível o tráfico privilegiado, na medida em que o réu não é primário e de bons antecedentes.

Quanto à detração (art. 387, § 2º, do CPP), entendo que é matéria afeta à execução penal (art. 66, III, 'c', da Lei de Execução Penal). Ademais, não alteraria o

regime inicial na hipótese.

Estabeleço: [a] como regime inicial, o fechado, em razão do montante da pena e da existência de reincidência (art. 33, § 2º, 'b', do CP); e [b] o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos (art. 49, § 1º, do CP), notadamente por não haver outros elementos que possam indicar em sentido contrário.

No ponto, cabe destacar que: [a] "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito" (Súmula n. 440 do STJ); [b] "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" (Súmula n. 719 do STF); e [c] "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou superior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (Súmula n. 269 do STJ).

Em razão do montante da pena, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito (art. 44, inciso I, do CP) ou de realizar a sua suspensão condicional (art. 77, caput do CP).

2.4 A indenização mínima

Deixo de fixar indenização mínima para a hipótese vertente, porquanto não houve pedido expresso nesse sentido na denúncia, o que impede sua concessão, conforme entendimento da Corte de Cidadania (AgRg no REsp 1673181/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018).

Ademais, mesmo que realizado o pedido em alegações finais, tal situação não é suficiente para fins de concessão, notadamente por inviabilizar o contraditório e a ampla defesa acerca do tema.

2.5 A prisão preventiva

No mais, deve ser mantida a prisão preventiva dos réus, porquanto convergentes os requisitos consistentes em condições de admissibilidade, indicativos de cometimento de crime (*fumus commissi delicti*), risco de liberdade (*periculum libertatis*) e proporcionalidade, conforme arts. 282, I e II, 312 e 313, do CPP.

Quanto aos demais pressupostos, verifico que: [a] a situação versa sobre crime de doloso com pena máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP); [b] há prova da ocorrência do fato típico, ilícito e culpável e da autoria do agente, conforme fundamentação desta sentença; e [c] presente o perigo de liberdade (*periculum libertatis*) e insuficientes as medidas alternativas, conforme art. 282, § 6º, do CPP.

Ademais, a prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública (preservação de situação de paz e sensação de segurança), mormente ante os indicativos de probabilidade de reiteração criminosa, porque o réu é reincidente, tendo cometido crimes patrimoniais e também da mesma natureza do delito analisado nesta sentença. Por fim, na hipótese em tela há equilíbrio entre os limites de excesso e insuficiência da medida, porquanto a prisão processual permite assegurar a adequada e razoável repressão da criminalidade, sem, entretanto, destruir o núcleo essencial de direitos fundamentais dos envolvidos.

3 Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 387 do Código de Processo Penal, condeno o réu pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação supra.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Contudo, a respectiva exigibilidade está suspensa, durante o prazo extintivo de 5 (cinco) anos, em face da presunção de hipossuficiência financeira, consoante arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC.

Declaro o perdimento de eventual arma de fogo e de munição apreendida em favor da União (art. 91, II, alínea 'a', do CP), para os fins dos arts. 25 e 32, parágrafo único, do Estatuto do Desarmamento, se o caso.

Determino a perda de eventual fiança, cujo valor será vertido para pagamento das despesas processuais e de eventual indenização para vítima, nos termos do art. 336 do CPP, se o caso.

Determino a destruição de eventuais drogas ainda existentes, se o caso.
Após o trânsito em julgado: [a] comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da CF; [b] formem-se os autos de execução; e [c] proceda-se às demais determinações de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpridas todas as determinações, arquivem-se.
São Paulo, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA